

1. 判决书字号

广东省高级人民法院(2023)粤刑终10号刑事判决书

2. 案由：走私国家禁止进出口的货物罪、妨害公务罪、危险驾驶罪

【基本案情】

2021年7月12日下午，被告人钟某等人按照同案人雷某（另案处理）的安排，组织他人在某村某路江边停车场将走私入境的冻品卸载、装运。次日凌晨，民警对该停车场进行搜查，查获冻品共计26.585吨，总价值147.7475万元。

2021年7月13日凌晨，被告人叶某驾驶货车（车尾喷涂粤A9×xx×号牌）搭载押车人员被告人田某，运输走私冻肉行驶至某路及某大道红绿灯路口处时，遇缉私民警拦截，叶某遂驾车逃离。当货车行驶至某大道路段，民警驾驶两辆轻型栏板货车（即皮卡车，车牌号分别为粤AS××××和粤A3××××）共同对粤A9×xx×号牌货车实施堵截。其中，粤AS××××号牌车行至货车车头意图逼停货车，车上民警打开车窗持工作证向货车驾驶员及车内人员表明身份，用手势示意其停车。叶某继续驾驶货车撞击粤AS××××号牌车尾部，致该车横挡在货车车头处，其仍驾驶货车推行该车向前行驶约60米，致车损严重，同时造成某大道中间近20米白色铁栅栏被撞倒碾轧，靠近右侧人行道旁的数根铁柱护栏均被撞倒。直到车上民警持枪用手势倒数，叶某、田某才停下货车并试图逃跑，后被民警抓获。经鉴定，前述两辆执法轻型栏板货车的损失价格共计18250元。此外，钟某还有醉驾等犯罪事实。

【案件焦点】

叶某、田某在运输走私冻肉逃离过程中，驾驶车辆撞击、推行民警执法车辆，构成妨害公务罪还是袭警罪。

【法院裁判要旨】

广东省广州市中级人民法院经审理认为：被告人钟某、叶某、田某等人的行为均已构成走私国家禁止进出口的货物罪；被告人叶某、田某的行为还构成袭警罪；被告人钟某的行为还构成危险驾驶罪。据此，以走私国家禁止进出口

的货物罪、危险驾驶罪判处钟某有期徒刑九年，并处罚金12000元。以走私国家禁止进出口的货物罪、袭警罪判处叶某有期徒刑七年，并处罚金5万元；判处田某有期徒刑六年，并处罚金4万元。以走私国家禁止进出口的货物罪判处其他被告人有期徒刑九年至一年六个月不等，并处罚金。

一审宣判后，钟某、叶某、田某等人提出上诉。

广东省高级人民法院经审理认为：原判认定基本事实清楚，证据确实、充分，判决各上诉人、原审被告入犯走私国家禁止进出口的货物罪及上诉人钟某犯危险驾驶罪的定罪准确，审判程序合法。但对上诉人叶某、田某暴力拒捕的部分事实认定有误，予以纠正。关于该部分事实的定性，叶某在田某的指使下虽然有驾驶货车撞击执法车辆的行为，但车上民警未受到人身攻击，货车的推行速度也不足以达到严重危及人身安全的程度，可见叶某、田某主观上并无积极追求袭击正在执行职务的人民警察的故意，客观上驾驶货车撞击执法车辆是为了逃避检查，并非暴力袭击，根据主客观一致及罪责刑相适应原则，其行为不构成袭警罪，应认定为妨害公务罪。此外，对上诉人钟某等人的量刑不符合罪责刑相适应原则，应予纠正。据此，判决如下：

以走私国家禁止进出口的货物罪、危险驾驶罪判处钟某有期徒刑八年，并处罚金12000元。以走私国家禁止进出口的货物罪、妨害公务罪判处叶某有期徒刑五年，并处罚金5万元；判处田某有期徒刑四年，并处罚金4万元。以走私国家禁止进出口的货物罪判处其他被告人有期徒刑八年至一年六个月不等，并处罚金。

【法官后语】

本案的争议焦点是被告人叶某、田某暴力拒捕的行为构成妨害公务罪还是袭警罪。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定了妨害公务罪和袭警罪两个罪名，妨害公务罪是指以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为，袭警罪是指暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的行为。从立法沿革看，袭警原先作为妨害公务罪的从重处罚情节，后经《中华人民共和国刑法修正案(十一)》规定为特定犯罪，可见袭警罪是从妨害公务罪中抽离出

来的罪名，二者为特别条款与一般条款的关系。成立袭警罪以符合妨害公务罪的构成要件为前提，同时要额外满足其他构成要件。本案中，叶某、田某暴力拒捕的行为符合妨害公务罪的构成要件没有争议，主要问题在于其二人的行为是否进一步构成袭警罪。对此，需要从客观和主观两方面进行分析辨别。

一、客观上从暴力的对象及程度区分妨害公务罪与袭警罪

妨害公务罪中的暴力是广义的暴力，是指对依法执行职务的国家机关工作人员行使有形力。此种暴力不要求直接对国家机关工作人员的身体实施暴力，通过对物实施暴力从而间接影响职务行为正常实施的，也可以构成妨害公务罪。例如，通过打砸执行职务人员使用车辆或者其他设备，阻碍职务行为的，可能成立妨害公务罪。袭警罪中的暴力则是指狭义的暴力，即对人民警察的身体行使有形力，其对象只能是人民警察，不包括其他国家机关工作人员。此种暴力系对人民警察的人身攻击，此种攻击至少对人民警察的人身安全有具体的危险，对人身安全不具有现实危险的，不宜被认定为袭警罪。同时，从袭警罪的罪状描述来看，袭击是指出其不意的突然攻击，渐进式的抵抗，不具备攻击的瞬时性，也不宜被认定为袭警罪。

本案中，叶某、田某驾驶货车运输走私冻品逃离民警追捕，在逃离过程中，两辆执法车辆欲前后夹击截停叶某、田某二人驾驶的货车，当一辆执法车辆加速超车实施堵截时，叶某、田某二人驾车撞击该执法车辆尾部并向前推行约60米，致车损严重。从客观上看，若行为人驾车撞击针对的是人民警察的身体，能够通过撞击车辆伤害车内警察，则可以构成袭警罪。但本案中执法车辆

与叶某、田某二人驾驶车辆先是并行，民警加速超车意欲截停，叶某、田某二人才撞上执法车辆尾部，并将执法车辆向前推行约60米，在整个过程中，叶某、田某二人并未直接针对民警进行撞击，向前推行的速度也很慢，事实上也未达到危及人身安全的程度，同时，此种撞击也并非瞬时性的袭击，不属于袭警罪中的暴力，在客观上仅符合妨害公务罪的构成要件。

二、主观上从实施暴力的认识和目的区分妨害公务罪与袭警罪
构成妨害公务罪，要求行为人主观上明知国家机关工作人员正在依法执行

职务，而故意以暴力、威胁方法予以阻碍。袭警罪则不仅要求行为人对暴力阻碍人民警察执行职务有认识，还要求有对人民警察进行人身攻击的故意。若行为人为采取暴力手段妨害公务，过失致使人民警察遭受人身伤害，不构成袭警罪。

本案中，叶某、田某均辩称不知道当时拦车的是警察，以为是“黑吃黑”，其他同案人也供述称被要求遇到“黑吃黑”拦车抢货的要继续撞过去。经查，当晚执法的民警虽然开的都是民用号牌的车，但车上有穿着制服的辅警、有人佩戴证件，民警在截停过程中多次贴靠开窗表明身份，打手势呼叫，在被推行之后掏枪警告，在货车仍不刹停的情况下朝天鸣枪示警，最后才拿枪对着叶某打手势倒数。可见执法的民警是理性、克制地逐步加大力度的，此过程持续了一段时间、经过相当长的路段，叶某和田某坐在货车驾驶室，视野较高，应当能够意识到是警察在进行缉私执法活动。但其二人驾驶货车强行撞击执法车辆是为了逃避检查、逃离现场，而不是意欲对警察进行人身攻击，没有袭警的故意，不构成袭警罪。

综上，妨害公务罪与袭警罪在客观上存在暴力对象及程度的不同，主观上存在对暴力的认识及目的的不同。本案二被告人驾驶车辆为了逃避追捕而撞击执法车辆，属于以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，应认定为妨害公务罪，但此种暴力手段没有伤害民警人身安全的现实危险，不构成袭警罪。

编写人：广东省高级人民法院 刘晓光 张伟隆

以航道清淤为名在内河非法采砂， 情节严重的，构成非法采矿罪

——仇某等非法采矿，掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01刑终448号刑事裁定书

2. 案由：非法采矿罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

2021年6月中旬至8月，被告人仇某、张某在未取得河道采砂许可证的情况下，组织被告人张某及陈某、陶某等人至某码头附近水域采砂。被告人仇某、张某经分别与被告人简某、蔡某事先共谋，简某与王某事先共谋，由仇某、张某组织采砂、安排黄某等运砂船将开采的河砂运至码头过驳，由王某等人提供码头过驳，由简某、蔡某等人销售河砂。

因航道堵塞，2021年6月28日，某市交通运输局等部门就恢复航道畅通召开应急疏浚会议，确定抢通疏浚航段。2021年6月29日至7月4日，仇某等人协助应急疏浚。

2021年6月中旬至8月，仇某、张某等人在某码头附近水域采砂共计57662.58吨，价值2821939.84元。其中，23948吨河砂由简某等人收购并销售，均运至王某经营或联系、安排的码头过驳。12386.76吨河砂由蔡某收购并销售，均运至彭某、周某经营的码头过驳。

【案件焦点】

1. 以航道疏浚为名在内河非法采砂的行为，是否构成非法采矿罪；2. 非法采砂期间，行政机关组织应急疏浚的部分，是否计入非法采砂犯罪数额；3. 掩饰、隐瞒犯罪所得行为人与上游非法采砂行为人“事前”通谋的时间节点如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省如皋市人民法院经审理认为：河砂属河流相沉积天然石英砂，主要化学成分为二氧化硅，经长期地质作用形成。仇某等在河道管理范围内挖掘售卖河砂，查扣物样品检测结论印证其矿产资源属性。各被告人以河砂为目标，且能明确认识到开采、运输、过驳、销售的是河砂，而非土。根据主客观相统一原则，本案开采的河砂属于矿产资源。河砂中的泥质含量不影响其矿产资源属性。建筑用砂标准是工程建筑上对砂的技术性要求，属于产品标准，不是认定河砂矿产资源属性的依据。

在案证据能够证明2021年6月底7月初，因案涉水域发生航道堵塞，海事等部门经会商，组织包括案涉采砂船在内的船舶进行航道应急疏浚，未涉及疏浚出的物品如何处置。虽然仇某组织购买采砂船、实施非法采砂行为在先，协助应急疏浚在后，但应急疏浚期间实施的采砂行为应当视为在行政主管部门安排之下所实施的修复抢通，客观上与未取得河道采砂许可证而擅自采砂的行为存在本质区别。因为非法采砂行为侵犯的法益是砂资源的所有权和国家的砂资源管理制度，而根据行政主管部门的安排进行应急疏浚的行为不应当受到刑法的否定性评价，不应以仇某等人擅自将应急疏浚出的河砂进行销售而反向认定其协助应急疏浚的行为系非法采砂行为。因此，应急疏浚期间的采砂数额应当从犯罪数额中扣除。

明知是犯罪所得的矿产品而予以转移、收购、代为销售，且事前与非法采矿犯罪分子通谋的，以非法采矿罪的共犯论处。判断“事前”的时间节点应当以掩饰、隐瞒行为人参与的时间为依据，与非法采砂行为是否已经开始着手实施并无关联，只要上游犯罪尚未完成即可。简某等四人明知仇某等非法采砂的

犯罪内容、危害后果而在收购、销售之前与其通谋，形成共同犯罪故意，客观上对于仇某等人非法采砂犯罪行为予以配合，应当以共犯论处。据此，以非法采矿罪对仇某等17人判处有期徒刑四年九个月至八个月不等，处罚金50万元至3万元不等，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对彭某、周某分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金5万元；对蔡某以非法采矿罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元。

一审宣判后，被告人提出上诉。

江苏省南京市中级人民法院经审理认为：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是一起典型的内河非法采砂案。涉及的争议问题主要包括以下三个：一是河砂能否认定为矿产资源；二是行政机关组织应急疏浚的采砂数量，是否计入非法采砂犯罪数额；三是掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游盗采犯罪事前通谋的认定。

一、河砂具有矿产资源属性，可以成为非法采矿罪的犯罪对象

矿山砂石、江砂的矿产资源属性一般没有争议。但法律法规对于矿产资源的范围并没有统一的技术标准可供鉴别，仅在《中华人民共和国矿产资源法实施细则》^①及其所附的《矿产资源分类细目》^②中提出了定义，并列举了矿产资源的矿种和分类。

与江砂不同的是，河砂中的含泥量较高、砂子细度模数较低、销售价值也远远低于江砂，不法分子往往以河砂不属于矿产资源为由提出辩解，试图逃脱

^①《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第二条规定，矿产资源是指由地质作用形成的，具有利用价值的，呈固态、液态、气态的自然资源。

^②该分类细目在对非金属矿产的列举中，包括天然石英砂(玻璃用砂、铸型用砂、建筑用砂、水泥配料用砂、水泥标准砂、砖瓦用砂)。

法律制裁。

在判断河砂是否属于矿产资源时，应当坚持主客观相一致的原则。客观上，河砂属河流相沉积天然石英砂，主要成分为二氧化硅，经长期地质作用形成，属于《矿产资源分类细目》中的天然石英砂。因此，河砂的矿产资源属性在客观上毋庸置疑。主观上，需要结合在案证据，判断行为人在盗采河砂过程中，是否认识到盗采的对象是具有经济价值的河砂，而非土。

司法实践中，由于河砂的含泥量较高、细度模数较低，被告人、辩护人往往以河砂达不到建筑用砂标准为由提出辩解，认为河砂不属于矿产资源，但上述观点难以成立。这是因为，从河道中直接开采出来的砂称为原状砂，其中泥质含量相对成品砂而言较高符合常理，但是，河砂中的泥质含量不影响河砂的矿产资源属性。建筑用砂标准是工程建筑上对砂的技术性要求，属于产品标准，并非认定河砂矿产资源属性的依据。且河砂的含泥量、细度模数影响的是河砂价值，无论是销赃金额还是认定价格，均包含上述因素，而且会作为量刑因素予以体现。

二、犯罪事实的认定不仅要从形式上判断是否符合构成要件，更需进行实质违法性的判断

犯罪行为必须是实质上为法律所不允许的行为，即必须是违法的行为。所谓违法，就是指行为违反法律，为法律所不允许。违法性的实质是对法益的侵害与威胁。刑法的任务与目的是保护法益。换言之，刑法之所以以刑罚禁止某种行为，是因为它侵害或者威胁了法益。实质违法性判断，有利于评价行为的违法程度，合理确定正当化事由的根据与范围。

对于非法采矿罪等行政犯，均以违反行政法律法规为前提，因此，与自然犯相比，在认定行政犯是否构成犯罪以及具体的犯罪事实时，不仅要从形式上判断是否符合构成要件，更有必要进行违法性的实质判断，否则，极易陷入机械司法的怪圈，进而得出违反常情常理的结论。

在被告人非法采砂期间，案涉水域发生航道堵塞，海事等部门组织包括案涉采砂船在内的船舶进行航道应急疏浚，并未涉及疏浚出的物品如何处置。虽

然被告人仇某等人组织实施非法采砂行为在先，协助海事等部门应急疏浚在后，但应急疏浚期间实施的采砂行为应当视为在行政主管部门安排之下所实施的修复抢通，客观上与未取得河道采砂许可证而擅自采砂的行为存在本质区别。因为非法采砂行为侵犯的法益是砂资源的所有权和国家的砂资源管理制度，而根据行政主管部门的安排进行应急疏浚的行为不应当受到刑法的否定性评价，不应以仇某等人擅自将应急疏浚出的河砂进行销售而反向认定其协助应急疏浚的行为系非法采砂行为。基于上述实质违法性判断，该案将应急疏浚期间的采砂数额从犯罪数额中进行了扣减。

三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游盗采犯罪事前通谋的认定

实践中，一些行为人未直接实施盗采行为，但在盗采、运输、销赃等环节充当“黄牛”，提供便利条件或者居间联络，对盗采行为的实现、持续实施或者转化为经济利益起到了实质性的帮助作用。对此类行为，一方面，应当坚持“全要素、全环节、全链条”打击；另一方面，应当依据法律规定和共同犯罪理论，准确区分盗采矿产资源帮助型共犯与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

具体而言，认定共犯的关键在于，主观上行为人存在意思联络，客观上帮助行为与本罪犯罪后果之间存在因果关系。掩饰、隐瞒犯罪所得的行为是事后帮助行为，“犯罪所得”中的“犯罪”应当是指既遂犯罪。对于事前与非法采砂犯罪分子通谋，实施掩饰、隐瞒犯罪所得的，主观上明知非法采砂行为人的犯罪内容、危害后果而与其通谋，形成共同的犯罪故意，客观上对非法采砂犯罪分子实施犯罪予以配合，应当以共同犯罪论处。

可见，上下游犯罪行为人是否存在“事前”通谋，直接关系到下游行为的性质认定。判断“事前”的时间节点应当以掩饰、隐瞒行为人参与的时间为依据，即掩饰、隐瞒行为人在参与犯罪之前，与盗采行为人进行通谋，加入犯罪，与非法采砂行为是否已经开始着手实施并无关联，只要上游犯罪尚未完成即可。二者的“事前”共谋既包括在上游非法采砂实行行为实施之前形成，也包括在上游犯罪实施过程中形成。如果上游犯罪既遂之后才知道上游犯罪行为的，自然不能认定为与上游犯罪人通谋。

实践中，存在掩饰、隐瞒行为人事先并未与上游盗采行为人通谋，而是在上游犯罪尚未完成时介入，但其并未直接参与上游盗采犯罪，而是以掩饰、隐瞒的方式协助盗采行为人完成犯罪，应当认定为非法采矿罪的共犯。仇某与陈某等人盗采河砂在先，在此过程中，简某等四人加入，并与仇某形成非法采砂的共同犯罪故意，而后按照约定分工，简某一方实施收购、销售河砂等行为，应当以共犯论处。

编写人：江苏省如皋市人民法院 张弦

私募基金领域非法集资行为的定性

——某基金公司、闫某某等非法吸收公众存款案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省廊坊市中级人民法院(2023)冀10刑终119号刑事裁定书

2. 案由：非法吸收公众存款罪

【基本案情】

被告单位某基金公司于2014年11月18日注册成立，靳某某担任该公司法定代表人，被告人闫某某担任总经理，被告人黄某某担任市场部总经理。2015年，该公司经中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，2019年7月26日，中国证券投资基金业协会注销该公司私募基金管理人登记。

2016年至2019年，该公司发行多个合伙制私募股权投资基金，期间违反私募基金投资规定，以私募基金投资名义通过公开宣传的方式与集资参与人签订合同，并承诺返还本息，向社会不特定人群4万余人次吸收资金，截至2019

年8月1日，共计吸收本金人民币2310700000元，兑付本金1650277500元，支付利息共计77498720元，尚欠本金660422500元未兑付。被告人闫某某、黄某某作为该公司的直接负责的主管人员，积极参与实施该公司的非法吸收公众存款行为。

【案件焦点】

1. 经依法登记的私募基金管理人通过发售合法备案的私募基金向不特定社会公众吸收资金的行为性质应如何认定；2. 私募基金领域非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪应如何区分。

【法院裁判要旨】

河北省廊坊市广阳区人民法院经审理认为：被告单位某基金公司以私募基金投资名义通过公开宣传的方式与集资参与人签订合同，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定人群吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人闫某某、黄某某作为某基金公司的高级管理人员，积极参与该公司的犯罪行为，系单位犯罪中直接负责的主管人员，二人行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，闫某某、黄某某起主要作用，均系主犯。闫某某、黄某某主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人闫某某、黄某某无前科劣迹，系初犯，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。

河北省廊坊市广阳区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第一项、第二款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：

一、被告单位某基金公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币30万元；

二、被告人闫某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；

三、被告人黄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；

四、公安机关扣押的涉案资产予以追缴，返还集资参与人；

五、被告单位某基金公司、被告人闫某某、黄某某非法吸收公众存款的违法所得予以追缴，返还集资参与人。

一审宣判后，公诉机关提起抗诉，认为被告单位某基金公司、被告人闫某某、黄某某在被告单位被注销私募基金管理人资质后，继续非法集资的行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，原审判决未予认定确有错误。被告人闫某某、黄某某提起上诉，认为一审判决量刑过重。

河北省廊坊市中级人民法院经审理认为：在案证据证实，某基金公司吸收集资参与人投资后，确有正常投资和经营活动，同时对集资参与人也有还本付息行为，其并非以非法占有为目的，骗取集资参与人资金，其行为符合非法吸收公众存款罪构成要件，且属数额巨大。在2019年7月26日中国证券投资基金业协会注销某基金公司私募基金管理人资质后至2019年8月1日，某基金公司继续以在中基协备案尚未清算的某股权投资基金名义吸收资金的行为，应当认定为非法吸收公众存款行为的延续。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。

河北省廊坊市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项、第二百四十四条的规定，作出如下裁定：

驳回抗诉、上诉，维持原判。

【法官后语】

一、私募基金领域非法吸收公众存款行为的认定

非法吸收公众存款行为是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪成立的基础。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，非法吸收公众存款行为具有非法性、公开性、利诱性、社

会性等四个特征要件。其中，非法性是认定吸收公众存款行为构罪的前提条件，体现为行为主体未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金。这里的“未经有关部门依法许可”，仅适用于法律明确规定应当审批而未经审批许可的非法融资行为。对于私募基金而言，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金监督管理条例》的相关规定，私募基金管理机构的设立和基金的发行实行行政审批豁免，私募基金管理人应当向基金业协会申请登记，募集完毕后办理备案；登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可。可见，私募基金登记和备案并不属于“有关部门依法许可”，私募基金管理人的主体资格和私募基金的备案情况只是基本的形式要件，无论私募基金管理人是否按规定办理登记并为发行的基金进行备案，均不影响对集资行为非法性的认定。本案中，被告单位虽按规定进行了登记，发行的涉案基金亦进行了备案，但并不意味其集资行为合法。被告单位披着合法私募基金的外衣，通过与集资参与人签订私募基金投资合同吸收资金，对其实施的集资行为的性质，应当根据法律和金融法规对私募基金募集对象、募集方式、收益分配等方面的相关规定进行实质审查。其集资行为违背私募基金非公开募集、收益不固定及投资者特定化等特性，因此不属于私募基金的合法经营行为。结合被告单位通过公开宣传吸引了大量不特定社会公众参与投资，并向投资人承诺固定年收益，符合非法吸收公众存款的公开性、利诱性、社会性等要件特征，其行为系非法吸收公众存款行为。

二、私募基金领域非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的适用

（一）非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别，在于行为人的主观上是否具有非法占有目的。对集资诈骗犯罪中“非法占有目的”的认定，要坚持主客观相一致的原则，不能单纯以诈骗方法代替非法占有目的的认定，也不能仅根据损失结果客观归罪。对于涉私募基金非法集资案件中行为人是否具有非法占有目的，应综合考察私募基金运行全过程的基础上，从以下角度进行判断：第一，私募基金募集阶段，宣称的投资项目是否系虚构，是否明显不具有盈利可

